

노동관행(Betriebliche Übung)에 따른 급부청구권의 형성과 소멸*

— 독일에서의 최신논의를 중심으로 —

권 혁**

目 次

I. 서설	IV. 노동관행을 통한 노동관행
II. 노동관행의 급부청구권 형	의 배제?
성근거에 대한 논의	V. 요약 및 결론
III. 계약설에 기한 노동관행의	
성립요건	

I. 서설

1. 노동법의 法源

法源이란 대체로 법적 분쟁을 해결하기 위하여 법관이 기준으로 삼아야 하는 재판규범의 존재형식으로 개념정의 된다.¹⁾ 사법관계에서 법적 분쟁의 해소는 정당한 권리와 의무의 존부를 확인하는 것에 다름 아니다. 법원(Rechtsquelle)이란, 원칙적으로 당사자 상호간에 형성되는 ‘권리(Recht)’의 ‘발생원천(Quelle)’으로 이해될 수 있다. 통상 사적 계약관계에서 권리의 발생원천은 당사자 간의 명확한 합의나 또는 입법자가 부여

* 논문투고일자 06.11.5, 심사일자 06.11.30, 심사완료일자 06.12.05

** 고려대 법과대학 강사, 법학박사

1) 김형배, 『노동법』, 신판전정판, 2005, 박영사, 135쪽 이하.

한 객관적 질서로서 법규범으로 대별될 수 있다. 근로계약관계를 대상으로 하는 노동법의 법원으로는 성문의 노동관련 규정 이외에도 단체협약, 노동조합규약, 사용자의 취업규칙, 근로계약, 사용자의 지시권, 노동관습법, 조리 등이 있다고 하는 데, 이러한 차원에서 이들은 각각 객관적 질서로서 주어지는 규범적 차원의 법원과 당사자 간의 의사합치(계약) 차원의 법원으로 크게 대별하여 볼 수 있음은 물론이다. 요컨대 성문의 노동관련 법률이나 관습법, 그리고 조리 등은 계약당사자의 의사와는 상관없이 객관적으로 입법자나 법관에 의해 형성되고 확인된 것으로서 규범적 성격을 갖는다. 이와 달리 단체협약이나 취업규칙 그리고 근로계약 등은 계약의 당사자로서 사용자와 근로자 간의 합의를 통해 법원으로서 권리와 의무를 형성하게 되므로 계약적 성격을 갖는 것이다.

2. 노동관행의 개념

종래 노동법의 특유한 법원으로서 ‘노동관행(Betriebliche Übung)’을 들고 있다.²⁾ 노동관행이라 함은, 특정 사업체의 근로자 다수를 대상으로 하여³⁾ 사용자가 근로계약과 같은 계약적 근거나 다른 법적 근거 없이 일정한 급부지급을 반복하여 옴으로써, 근로자에게 그러한 급부지급이 앞으로 계속될 것이라는 기대를 형성하는 경우에, 특별히 근로자에게 이에 관한 급부청구권 형성을 인정하게 되는데,⁴⁾ 이때 급부청구권이라는 권리의 형성근거를 말한다.⁵⁾ 이러한 노동관행은 개별적 당사자로서 근로

2) 김유성, 『노동법 I』, 2005, 법문사, 14쪽; 임종률, 『노동법』, 4판, 2004, 박영사, 9쪽.

3) Seiter, *Die Betriebsübung*, 1967, S. 134.

4) 독일에서 근로자의 급부청구권이 노동관행을 통해 인정되기 시작한 것은, 제국법원 당시로 거슬러 올라간다. 즉, 1928년 독일 라이프찌히 은행이 파산한 이후 그 파산관재인에 대하여 근로자가 종래 관행으로 지급하여 오던 성탄절 상여금을 지급해달라고 요구한 사건이다. 1929년 당시 독일제국법원은 성탄절상여금지급이 계약의 내용으로 인정된다고 하여 이를 받아들이는 판결(RAGE 6, 65)을 한 바 있다.

5) BAG AP Nr. 2 zu § 242 BGB Betriebliche Übung; Gamillscheg, Festschr. Hilger/Stumpf, 1983, S. 227 (243ff.); Hromadka, NZA 1984, 241 (243).

자와 사용자 사이에서 인정되는 경우만이 아니라, 노동조합 또는 근로자 집단과 사용 사이에 있었던 경우에도 인정될 수 있다.⁶⁾ 예컨대 단체교섭의 절차, 조합 활동의 절차 및 조건 그 밖에 편의조건 등에 관하여 노사 간 일정한 취급이 반복되는 경우가 있을 수 있기 때문이다. 이렇게 노동관행은 단체협약이나 취업규칙 기타 근로조건의 형성이나 해석의 기준이 된다.⁷⁾ 이하에서는 이때 종래의 일정한 취급을 그대로 반복할 것으로 요구할 수 있도록 하는 청구권 근거로서의 노동관행에 관한 논의로 국한하여 설명하기로 한다. 노동관행은 그 개념구조를 살펴볼 때, 당사자간 합의를 통한 것도 아니며, 그렇다고 입법자에 의해 주어진 질서규범이라고 평가하기도 어려운 측면이 있다. 오히려 노동관행은 단지 반복된 급부 ‘사실(Tatsachen)’로서의 본질을 가질 뿐이다.

3. 문제의 소재와 논의의 현황

결국 반복된 급부지급 ‘사실’로부터 사용자에게는 장차에도 그러한 급부를 계속 지급해야 할 채권법적 의무가 인정되고, 근로자는 사용자에게 대하여 급부청구권을 행사할 수 있게 되는 셈이다.⁸⁾ 종래 근로관계의 법원으로서 노동관행에 관한 독일에서의 논의는 이러한 반복된 사실로부터 급부청구권이 형성된 그 근거를 설명하기 위한 것이었다. 이 문제를 해결하기 위해 오랫동안 독일에서는 많은 시도가 있었으나,⁹⁾ 지금까지도 이에 관한 명확한 이론이 확립된 바 없이 미해결의 과제로 남아 있음을 부인할 수 없다.¹⁰⁾ 그러나 오늘날 연방노동법원의 입장은 대체로 명확한

6) 大判 2002.4.23, 2000다50701.

7) 임종률, 앞의 책, 270쪽; 박수근, “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력”, 『노동관계비평』, 2002, 129면 이하. 특히 단체협약과의 관계에서 발생하는 규범적 효력문제와 관련하여서는 동 논문 135면 이하.

8) 이러한 노동관행은 다수의 근로자를 대상으로 한 급부의 반복으로서 특정 근로자와의 개별적 급부관계에서 형성된 개별적 급부는 노동관행의 개념범주에 포섭될 수 없다(MünchHbArbR-Richardi, 2. Aufl., 2000, § 13 Betriebsübung Rdn.3).

9) MünchHbArbR-Richardi, 2. Auflage 2000, § 13 Betriebsübung Rdn. 5 ff.

10) Thüsing, NZA 2005, 718 (718).

것으로 보인다. 즉, 노동관행에 따라 근로자에게 일정한 법적 청구권이 인정된 법이론적 기초를 당사자 간의 묵시적 합의에서 찾고 있다.¹¹⁾ 1970년대 이후 노동관행이라는 고전적인 노동법상의 쟁점은 대체로 이렇게 일단락되는 것처럼 보였다. 그런데 한동안 잠자고 있던 노동관행에 관한 논의가 1990년 대 말 이후 독일 노동법학계에서 다시 한번 노동법상의 중요한 쟁점으로 떠올랐다. 그 계기가 된 것은, 노동관행으로 형성된 급부청구권의 내용이 —그 발생의 경우에 마찬가지로— 단지 불이익하게 변경된 급부의 지급과 수령의 반복사실에 따라 다시금 불이익하게 변경되거나, 아예 소멸할 수도 있어야 한다는 1997년 독일연방노동법원의 판단이었다.¹²⁾

요컨대 노동관행을 통해 형성된 급부의 내용은 사후적으로 변경되거나, 소멸될 수도 있음은 물론이다. 그러나 문제는 그 방식이다. 이 문제도 결국은 노동관행의 법이론적 본질에 밀접하게 관련되어 있다. 이하에서는 우선 노동관행에 따른 급부청구권이 어떠한 법이론적 기초 하에서 형성되는 것인지를 살펴보고, 이를 전제로 하여 향후 노동관행에 따라 형성된 급부청구권을 내용상 불이익하게 변경하거나, 아예 소멸하고자 하는 경우에, 그 방식에 대하여 설명하기로 한다.

II. 노동관행의 급부청구권 형성근거에 대한 논의

1. 견해의 대립

과거 반복적 사실개념으로서의 노동관행이 법적 급부청구권을 형성할 수 있는 근거와 관련하여 종래 독일에서는 크게 두 가지 견해가 대립하여 왔다. 우선 노동관행 사실에 대해 일정한 급부계약체결 즉, 의사 합의

11) BAG AP Nr. 10 zu § 242 BGB Betriebliche Übung; BAG AP Nr. 1 zu § 1 BetrVG Betriebliche Übung; BAG AP Nr.192 zu §611 BGB Gratifikation.

12) BAG NZA 1997, 1007.

치 차원에서 그 법적 본질을 이해하려는 입장을 들 수 있다. 다른 한편에서는 민법상의 신의칙(독일민법 제242조)을 통해 급부 청구권의 형성을 설명하려는 견해가 각각 유력하게 제시되어 온 바 있다.

1) 계약설

(1) 내용

독일연방노동법원은 노동관행에 따른 청구권의 발생과 사용자의 지급 의무에 대하여 당사자 간의 묵시적 계약에 따른 것으로 일관되게 파악하고 있다(이른바 ‘계약설’).¹³⁾ 즉, 노동관행이라고 평가될 수 있는 자발적 급부의 반복사실은 다음과 같은 두 가지 의사표시를 동시에 내포하고 있다고 한다. 우선 반복적으로 급부지급사실로부터 사용자의 청약의사가 존재하는 것으로 본다. 즉, 사용자의 반복적 지급은 “앞으로도 종래와 같은 급부지급을 법적 의무로서 부담하겠다”는 의사가 내재된 것으로 보아야 한다는 것이다.¹⁴⁾ 다른 한편 근로자가 당해 급부를 반복적으로 수령한 것에 관하여는 묵시적 승낙이라고 평가한다(§151 BGB).¹⁵⁾ 결국 계약설에 따른 경우 종래 반복적으로 지급되어 온 급부의 내용은 곧바로 —합의를 통해 형성된— 근로계약의 내용으로 된다.¹⁶⁾

13) BAG AP Nr.10 zu §242 BGB Betriebliche Übung; BAG AP Nr.1 zu §1 BetrVG Betriebliche Übung; BAG AP Nr.192 zu §611 BGB Gratifikation. 당시 이를 지지하는 학설로는 Säcker, *Privatautonomie und Übermachtkontrolle im ArbR*, 1972, S.485ff.

14) BAG AP Nr.22 zu §242 BGB Betriebliche Übung; BAG AP Nr.50 zu §242 BGB Betriebliche Übung.

15) BAG AP Nr.30 zu §242 BGB Gleichbehandlung; BAG AP Nr. 1 zu § 1 BetrAVG Betriebliche Übung.

16) LAG Schleswig-Holstein, DB 2000, 1769. 이 사건은 화물운송회사가 종래 수년에 걸쳐 근로자인 기사들이 도로교통위반을 하여 벌금을 부담해야 하는 경우 이를 대신하여 납부해 오고 있었다. 이 판결에서 법원은 대신 벌금을 납부하는 것이 당해 운송회사 근로자와의 계약내용으로 평가될 수 있는 한도에서 노동관행에 따른 근로자 측의 청구권 행사도 가능하다고 보았다.

(2) 비판적 평가

독일 판례가 일관된 입장으로 지지하고 있는 이러한 계약설은 반복된 급부지급과 그 수령이라는 ‘사실’로부터 곧바로 계약당사자 간의 청약과 승낙에 해당하는 의사표시성을 부여하게 되는 법이론적 어려움이 있다. 특히 객관적으로 반복된 급부지급사실로부터 사용자의 의무부담의사를 곧 바로 인정하는 것은 지나치게 인위적이라는 비판이 가능하다.¹⁷⁾

2) 신뢰책임설

(1) 내용

다른 한편 당사자 간의 합의를 통하여 급부청구권을 인정하려는 종래 법원의 입장과는 달리 민법상의 신의칙이라는 ‘객관적 규범’을 매개로 하여 노동관행의 청구권 성립근거를 찾으려는 입장이 있다(이른바 ‘신뢰책임설’). 이는 주로 독일 학계에서 선호되어 왔다고 할 수 있다.¹⁸⁾ 즉, 사용자가 자발적인 급부의 지급을 상당기간을 통해 반복하면 사실상 근로자는 당해 급부수령이 앞으로도 지속될 것이라는 데 대하여 일정한 신뢰가 발생하게 되고 근로자의 이러한 신뢰는 사법 상 보호되어야 한다는 것이다. 다른 한편 만약 사용자가 이른바 자신의 반복적 급부행위를 임의로 중단하게 되면 사용자의 그러한 행위는 이른바 금반언의 원칙에 반하는 것이 됨을 의미하기도 한다. 따라서 신뢰책임설에 따를 경우 사용자의 ‘계약적’ 의무로서 급부지급부담은 독일 민법 제242조상의 신의칙에서 그 법적 근거를 찾을 수 있게 된다.¹⁹⁾

17) 이에 대하여는 Seiter의 박사학위논문(Seiter, *Die Betriebsübung*, 1967.)에서 처음 본격적으로 제기되었다.

18) Canaris, *Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht*, 1971, S. 254ff.; Richardi, Anm. zu BAG AP Nr.142 zu §242 BGB Ruhegehalt; Hromadka NZA 1984, 241 (244); Singer ZfA 1993, 387 (494ff.). 우리 나라에서는 하경효, 『노동법사례연습』, 2판, 2006, 박영사, 76쪽.

19) 이러한 한도에서 규범설이라고 할 수 있다. 그 밖에도 Siebert는 사용자의 배려의무 차원에서 노동관행에 따른 일정한 급부가 법적 청구권을 형성한다고 주장한 바 있다(Siebert, BB 1955, 869 (871)).

(2) 비판적 평가

우선 계약설이 반복적인 급부지급 사실로부터 근로계약 당사자, 특히 사용자의 의무부담의사를 인정하고 있다는 점에서 지나치게 의제적인 측면이 없지 않으며, 이러한 점에서 신뢰책임설은 매우 설득력 있어 보이는 것이 사실이다. 그러나 오늘날 독일 학계에서 신뢰책임설은 다음과 같은 이론적 흠 때문에 더 이상 많은 지지를 얻고 있지 못하고 있다. 즉, 신뢰책임설은 추석상여금과 같이 근로자에게 유리한 ‘일방적’ 급부지급과 관련하여서는 효과적인 설명이 될 수 있으나, 그러한 급부지급에 일정한 근로자의 의무가 동반하는 경우에는 동 이론이 무력하게 되는 흠이 발생된다.²⁰⁾ 다시 말하면 근로자에게 이익이 되는 사용자의 반복된 호의적 급부에는 별도로 일정한 부담(Negative Interesssen)이 근로자에게 부과되어질 수도 있다.²¹⁾ 전체적으로 보아 근로자에게 유리한 급부이면 노동관행으로서 일정한 법적 청구권을 형성할 수 있기 때문이다.²²⁾ 그런데 문제는 노동관행에 따른 급부청구권의 성립 그 이면에 존재하게 되는 근로자의 의무발생에 대하여 신뢰책임으로는 설명하기 어렵다는데 있다. 왜냐하면 보호받아야 할 근로자의 신뢰란, 근로자 자신에게 기대되는 이익에 관한 것이지, 부담에 관한 것은 아니기 때문이다. 오히려 의무부분에 대한 신뢰는 사용자가 주장할 바인데, 근로계약관계에서 근로자의 의무에 해당되는 내용을 명문의 합의 없이, 사용자가 근로자의 부담부분에 대하여 단지 신뢰하였다는 이유만으로, 근로자의 부담이 법적 차원에서 의무화되는 것은 인정하기 어렵다. 왜냐하면 Canaris가 이미 적절히 지적한 바대로, 신뢰책임이 발생하기 위한 전제로서 반드시 당사자의 신뢰가 법

20) Preis, *Arbeitsrecht*, 2. Aufl., 2003, S.168.

21) 예컨대 종래 A회사가 창립이후 10년 동안 창립기념일이 공휴일이 아니라, 평일에 해당하여 근무가 이루어지는 경우에, 근로자에 대하여 1일분에 해당하는 임금의 두 배를 관행상 지급하여 온 경우를 생각해 볼 수 있다. 1일분의 임금 이외에 추가로 지급되는 임금의 100퍼센트 부분이 노동관행에 따른 지급분에 해당한다. 그런데 이러한 지급은 근로자가 창립기념일에 근로를 하는 경우에 인정되는 것이다. 따라서 만약 근로자가 창립기념일에 근무를 하지 않는 경우에는 지급되지 않는다. 다시 말하면 근로자가 노동관행에 따른 추가분의 보너스를 받기 위하여는 자신의 ‘근로’를 이행하여야 하는 것이다.

22) Preis, *Arbeitsrecht*, 2.Aufl., 2003, S.168.

적으로 보호되어야 할 가치가 있는 것이어야 하는 데,²³⁾ 사회적 약자로서 근로자 보호를 이념으로 하는 노동법상에서 그러한 사용자의 신뢰를 보호대상으로 하는 것은 아니기 때문이다.

3) 노동관습설

(1) 내용

우리 학계에서는 노동관행에 대하여 사실인 관습(민법 제106조)으로 파악하려는 견해가 유력하다.²⁴⁾ 사실인 관습이라 함은 사회관행에 의하여 발생한 사회생활규범이나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로 승인된 정도에 이르지 못한 경우를 말한다.²⁵⁾ 이러한 사실인 관습은 당사자 간의 의사를 보충하는 역할을 수행한다는 데 그 본질이 있다. 따라서 당사자가 의사를 통해 명확히 정한 바 없는 경우에 비로소 의미를 갖는다. 이러한 논리에 따를 경우, 사실인 관습설은 사실상 계약 설과 그 궤를 같이 한다고 할 수 있다.²⁶⁾

다른 한편 반복된 급부가 일정한 청구권을 형성하게 되는 것과 관련하여 이를 노동관습법차원에서 이해하려는 견해도 제기된 바 있다.²⁷⁾ 이는 우리 판례의 입장이기도 하다. 우리나라 대법원은 노동관행의 성립요건으로서 당사자 간의 규범의식의 존재가 인정되어야 한다고 봄으로써 대체로 노동관행을 묵시적 규범으로 파악하고 있다.²⁸⁾ 즉, 실제로 일정한 관행이 기업 내에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적 사실로 명확하게 승인되거나, 기업의 구성원이 아무런 이의를 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상 제도로서 확립되어 있어, 근로계약의 내용을 이루는 것으로 인정되는 경우처럼, 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 인정된다는 것이 판례의 입장이다.²⁹⁾ 이러한 입장을

23) Canaris, *Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht*, 1971, S.491.

24) 임종률, 앞의 책, 9쪽; 김형배, 앞의 책, 135쪽.

25) 大判 1983.6.14, 80다3231.

26) 같은 취지로는 임종률, 앞의 책, 9쪽.

27) Gamillscheg, *Festschr. Hilger/Stumpf*, 1983, S.227 (243ff.).

28) 大判 2002.4.23, 2000다50701; 大判 2001.10.23, 2001다53950; 大判 1996.5.10, 95다42270; 大判 1993.1.26, 92다11695.

취하게 되면, 경영관행은 사실상 객관적 규범성에 해당되는 노동법의 법원으로 분류될 것이다.³⁰⁾ 다만 우리나라의 학설 중에는 노동법의 경우 관습법과 사실인 관습을 엄격히 구별할 실익이 없다는 전제하에서, 판례의 입장과 동일한 차원에서 관습노동법으로 인정할 수 있다는 견해도 있다.³¹⁾

(2) 비판적 평가

우선 관습법은 법규범적 의식이 존재하는 관습이다. 사실인 관습도 법적 확신이 존재하지 않는다는 점에서 관습법과 다를 뿐, 관습으로서의 본질을 갖는다.³²⁾ 이 양자의 견해는 모두 반복된 급부지급사실이 관습에 이르렀음을 전제로 하여 법원성을 긍정하였다는 점에서는 공통적이다. 반복된 급부지급사실을 관습으로 평가하기 위하여는, 상당히 오랜 기간 동안 그러한 관행이 반복, 지속되어야 한다. 그런데 독일에서 노동관행이 문제된 사례를 보면, 대체로 연 1회씩 3회에 걸쳐 일정한 급부가 반복하여 지급된 경우에도 노동관행으로서 일정한 청구권을 근거지을 수 있다고 한다.³³⁾ 우리의 경우와 비교한다면, 3년간 연1회 지급된 정도의 급부 반복사실을 두고는 아직 사실인 ‘관습’으로 평가하기 어려울 것이다. 이러한 점에서 노동관행의 내용을 관습법이나 사실인 관습으로 파악하는 것은, 사실상 노동관행에 따른 청구권의 성립여지를 지나치게 좁게 파악하고 있음을 알 수 있다.³⁴⁾

그러나 근로관계 상의 일정한 호의적 지급에 대하여 일정한 청구권 형성을 특별히 인정하는 것은 관습성의 형성을 전제로만 한다고 보기는 어렵다. 왜냐하면 관습에 이를 정도가 아니더라도, 근로자는 사용자에 대하

29) 大判 1996.5.10, 95다42270.

30) 박수근, 앞의 논문, 134면 이하.

31) 이상운, 『노동법』, 2005, 법문사, 38쪽.

32) 전형배, “단체협약에 예정된 근무기간을 초과한기간에 대한 퇴직금 누진율의 판단 -노동관행을 인정하기 위한 시험적 기준- 대상판결: 대법원 2001.10.30. 선고 2001다24051 판결”, 『노동판례비평』, 2001, 81면 이하.

33) BAG DB 1956, 402; BAG DB 1956, 1039; BAG AP Nr.3 zu §611 BGB Gratifikation.

34) 大判 1999.9.3, 98다34393; 大判 1996.5.10, 95다42270.

여 사실상의 급부지급사실만으로 일정한 급부청구권을 행사할 수 있다는 것이, 노동법의 특유한 법원으로서 노동관행을 인정한 이유이기 때문이다.³⁵⁾

특히 호의적 급부지급이 관습법에 이르러, 비로소 일정한 법적 청구권을 형성하였다고 본다면, 사실상 민사법상의 일반적 법원으로서 관습법이 존재할 뿐이고, 노동법상의 특유한 법원으로서 노동관행이 별도로 언급될 것은 아니라고 할 것이다.

2. 소결

비록 일정한 급부사실 안에서 당사자의 일정한 의무부담의사를 찾아야 하는 법이론적 어려움은 있으나, 노동관행이 일정한 권리관계를 형성하는 근거를 당사자 간의 계약에서 찾는 것이 타당하다고 본다. 다만 중요한 것은 반복된 급부지급이 사실상 계약체결을 위한 사용자의 청약으로서 평가될 수 있어야 한다는 점이다. 또한 사용자의 급부지급에 대해 근로자의 반복된 수령사실로부터 청약에 대응하는 승낙의 의사표시가 인정될 수 있는가와 관련한 법적 판단가능성이 전제되어야 한다.³⁶⁾ | 하에서는 계약설에 따른 노동관행의 성립요건을 살펴보기로 한다.

III. 계약설에 기한 노동관행의 성립요건

1. 사용자의 계속적 급부 지급에 대한 ‘청약’의 존재

1) 호의적 급부의 반복적 지급

비록 계약의 내용으로 정한 바는 없지만, 사용자가 수차례에 걸쳐 일정한 급부를 반복하여 지급하게 되면 노동관행이 발생될 수 있다. 그렇

35) Hromadka, NZA 1984, 241 (243).

36) Preis, *Arbeitsrecht*, 2. Aufl., 2003, S.168.

다면 사용자가 구체적으로 어느 정도의 기간동안에 걸쳐 일정한 급부를 반복 지급하여야 비로소 노동관행이라는 법원이 인정될 수 있는가? 이에 대하여 종래 독일에서도 명확한 기준이 제시되어 있지는 않다. 따라서 근로계약관계의 당사자가 처해 있는 구체적 사정을 통해서 개별적으로 판단할 수밖에 없다.³⁷⁾ 다만 독일 연방노동법원의 판결례에 따를 경우, 사용자가 별도의 조건을 유보함이 없이 호의적인 급여(성당절상여금)를 3회 즉, 3년에 걸쳐 동일하게 지급하여 온 사실이 있다면, 이러한 사용자의 급여 지급은 법적 청구권을 근거지우는 노동관행으로서 평가될 수 있다고 한다.³⁸⁾

2) 청약의 내용으로서 사용자의 의무부담의사

계약설은 종래 반복된 급부제공사실에 대하여, 사용자가 근로자에 대하여 장차에도 그러한 급부지급을 의무로서 부담하겠다는 내용의 청약의 사표시로 파악한다. 이때 사용자의 의무부담의사가 실제로 존재하는가 하는 점은 이를 판단하는 데 고려되어야 할 사항이 아니다.³⁹⁾ 청약으로서의 적격성은 사용자가 아닌 근로자의 주관적 의사와 판단에 의해 좌우된다. 따라서 비록 사용자에게 그러한 의무부담의사가 없었더라도, 사용자의 반복된 급부지급으로 그 상대방인 근로자에게 “사용자가 스스로 종래 반복된 급부의 지급을 의무로서 부담하려고 한다”는 주관적 판단을 가능하게 하였다면, 사용자의 그러한 급부제공은 청약으로서 적격성을 갖춘 것이라고 평가할 수 있다. 따라서 사용자의 의무부담의사란, 단지 의사표시의 단순한 동기사실에 불과하다. 만약 사용자가 종래 반복하여 온 자신의 급부지급이 일정한 법적 의무를 부과할 수 있다는 사실에 대해 알지 못하였고, 이를 알았다면 이를 행하지 않았을 것임을 주장하여, ‘청약’의 의사표시를 취소할 수는 없다. 왜냐하면 법률효과에 대한 표의자의 착오는 원칙적으로 취소의 대상이 되지 않기 때문이다.⁴⁰⁾

37) Preis, *Arbeitsrecht*, 2. Aufl., 2003, S.168ff.

38) BAG AP Nr.47 zu §242 BGB Betriebliche Übung. 그 외에도 BAG DB 1956, 1039; BAG AP Nr.3 zu §611 BGB Gratifikation.

39) BGHZ 91, 324 (330). 이에 대한 비판으로는 Canaris NJW 1984, 2281ff.

3) 명시적 유보에 따른 의사표시성 배제

사용자가 종래 호의적 급부를 반복하여왔지만, 매년 자신의 급부가 단지 호의적인 것에 불과하고, 장차 법적 의무를 부담하려는 것은 아니라는 점을 명시적으로 근로자에게 표시할 수도 있다. 이러한 경우에는 비록 일정한 급부가 반복된 경우라도 그로부터 노동관행에 따른 급부청구권이 발생한다고 볼 수 없다. 왜냐하면 반복된 급부사실에도 불구하고 의사표시의 청약성을 도출할 수 없기 때문이다.⁴¹⁾ 다만 이때 사용자의 청약 성립의 배제를 실현하는 사용자의 호의성 유보조치는 단순히 당해 급부가 호의급부임을 나타내는 데 그쳐서는 안 된다. 이를 위해서는 사용자가 이러한 급부에 대해 장차 자신이 의무로서 부담하지 않겠다는 의사표시를 분명하게 나타내야만 한다.⁴²⁾ 또한 사용자의 호의유보가 근로자에 대하여 명시적으로 행하여진 바 없고, 단지 묵시적으로 행하여진 경우라도, 실제로 근로자 측이 이러한 급부지급의 호의성과 청구권 배제성에 대하여 명백하게 인식할 수 있을 정도에 이르렀다면, 이러한 한도에서는 노동관행에 따른 청구권 성립은 배제된다고 보는 것이 타당하다.⁴³⁾ 왜냐하면 근로자 측에서 사용자의 의사를 명백히 인식한 이상, 인식한 대로 법적 효과를 부여하는 것이 사적 자치의 본질적 요청에 부합하기 때문이다.

40) BAG NZA 1988, 735 (736).

41) Bepler, RdA 2004, 226 (230).

42) BAG AP Nr. 45 zu §242 BGB Betriebliche Übung. 본 판결에서 매 신년마다 업무 개시일에 맞추어 사기 진작을 위한 일정금액의 상여금을 지급하여 왔는데, 사용자가 이를 지급하면서 그때마다 ‘당해 상여금의 지급여부에 대하여는 신년 초에 별도의 절차에 따라 매년 개별적으로 결정된 것이므로, 장차 이에 대한 급부청구권은 인정될 수 없음’을 근로자 측에 밝히 왔다면, 당해 상여금 지급과 관련하여 노동관행에 기한 청구권 형성은 부인되어야 한다고 판시한 바 있다. 최근에 같은 취지의 판결로는 BAG NZA 2003, 557. 그 외에도 같은 취지로는 Bepler, RdA 2004, 226 (230); Hennige, NZA 1999, 289 (289ff.).

43) Bepler, RdA 2004, 226 (230).

2. 근로자의 급부수령 행위를 통한 ‘승낙’

1) 법적 기대를 수반한 급부수령

계약설에 따를 경우, 사용자의 반복된 급부에 대하여 해당 근로자가 이의를 제기함이 없이 이를 수령하여 왔다면, 이러한 수령행위는 곧 사용자의 청약에 대한 근로자의 승낙의 의사표시를 내포하고 있는 것이라고 평가할 수 있다. 왜냐하면 근로자는 통상 사용자의 반복된 급부지급에 대해, 장차 앞으로도 이러한 지급이 계속될 것을 예상·기대하면서 매번 이를 수령하는 것이기 때문이다.⁴⁴⁾

2) 동등대우의 원칙(Gleichbehandlungsprinzip)

새로이 신규로 고용된 근로자의 경우에는 사용자의 관행적 급부에 대해 이를 수령한 바 가 없었거나 혹은 있다 하여도 고작 1 - 2회에 그치게 되는데, 과연 신규근로자에게 그러한 기대를 바탕으로 한 수령을 승낙으로 평가하는 것이 가능한가하는 의문이 제기될 수 있다. 판단컨대 노동관행은 개별 근로자와의 특유한 계약형성이 아니고 다수 근로자와의 집단적 계약형성으로서의 본질을 지니며 그러한 한도에서 합의를 통해 형성된 집단적 근로조건이다. 이러한 점에서 각 개별 근로자의 구체적인 사정이 반드시 고려되어야 하는 것은 아니다. 오히려 이와 관련하여 무엇보다 우선하여야 할 점은 바로 근로계약관계의 일반 원칙으로서 이른바 동등대우의 원칙이다. 종래 오랫동안 근무하여 온 근로자에게만 노동관행에 따른 청구권 성립을 인정하는 것은 동등대우의 원칙에 반하는 것이 되므로, 노동관행에 따른 급부청구권은 신규근로자에게도 마찬가지로 적용되어야 한다.⁴⁵⁾

44) BAG AP Nr.1 zu §1 BetrAVG Betriebliche Übung.

45) BAG AP Nr.1 zu §1 BetrAVG Betriebliche Übung.

IV. 노동관행을 통한 노동관행의 배제?

1. 문제의 소재

노동관행에 따른 법적 청구권의 발생을 당사자 간의 계약으로 파악하는 한, 노동관행 상 지급되는 사용자의 급부는 결국 근로계약의 내용이 된다. 그런데 노동관행 상의 급부내용은 언제나 동일하게 유지될 수만은 없다. 이후 경영 상태가 악화되는 등 사정이 변경되면 그러한 급부의 내용은 되거나, 아예 소멸될 수도 있는 것이다. 문제는 그 방식이다. 원칙상 근로계약관계에서 그 내용을 - 특히 근로자 측에 불이익하게 - 사후적으로 변경하기 위해서는 근로자 측과 명시적인 합의를 시도하여야 한다.⁴⁶⁾ 다만 이러한 당사자 간의 근로조건 변경을 위한 개별적 합의에 대하여는 양 당사자 간의 지위가 대등하지 못하다는 문제 때문에, 독일의 경우 경영협의회(Betriebsrat)의 개입을 광범위하게 인정하고 있다.⁴⁷⁾ 다른 한편 우리의 경우는 근로조건이 취업규칙의 내용에 따르게 되는 경우, 그 불이익 변경에 대하여는 특별히 근로기준법 제97조에서 근로자 측의 집단적 동의를 요하도록 하고 있다. 이에 관한 법리는 노동관행에 따른 청구권의 소멸과 관련하여서도 마찬가지로 고려될 수 있어야 한다고 본다.⁴⁸⁾

최근 독일에서 여전히 문제가 되는 것은, 처음부터 합의를 통해 형성

46) 다만 독일의 경우 사용자는 일방적 수단으로서 변경해지(Veränderungskündigung)를 행사할 수 있다. 변경해지제도는 독일 해고제한법 제2조에 규정된 제도이다. 그러나 우리의 경우는 변경해지제도에 대하여 별도로 규정된 바가 없다. 변경해지가 해고제한법 상의 해고정당성을 충족하지 못하는 등 일방적 계약내용 변경의 가능성이 존재하지 않게 되면, 사용자로서는 근로자 측과 합의를 통한 근로계약내용의 변경에 나서게 된다.

47) 임금의 변경이나 근로 시간 등의 변경 그리고 신규고용 등의 문제에 대하여 경영협의회가 이에 개입할 수 있도록 법규정을 통해 이를 보장하고 있다 (§87, §99 BetrVG). 이에 관하여 자세히는 Wank, *Änderung von Arbeitsbedingungen* (Hrsg. Hromadka), S.35ff.

48) 서울고판 2000.8.10, 2000나8009; 김형배, 앞의 책, 138쪽; 박수근, 앞의 논문, 146면 이하.

된 근로계약 내용과 달리 묵시적 계약을 통해 형성된 노동관행상의 급부 내용을 — 마치 노동관행에 따른 급부청구권이 형성될 때와 마찬가지로 당사자 간의 명시적 합의나 변경해지가 없더라도 — 단지 변경된 급부의 반복적 지급과 수령만으로 불이익하게 변경하거나 아예 소멸시킬 수 있는지 여부이다. 1997년 독일 연방노동법원이 자신의 판결을 통해 근로자 측이 불이익 변경된 급부를 이의 없이 수령하였고 이러한 수령이 또한 반복되어왔다면, 근로자 측의 묵시적 승낙을 통한 노동관행급부의 소멸 또는 변경을 긍정한 바가 있다.⁴⁹⁾ 이에 관하여 이하에서 자세히 살펴보기로 한다.

2. 독일연방노동법원의 판결례

1) 사안의 내용

단체협약에 따르면, 사용자는 근로자 측에 대하여 세전임금 1개월분의 70퍼센트에 해당되는 금전을 성탄절상여금으로 지급하도록 되어 있었다. 그런데 1961년도 이래로 사용자는 아무런 별도의 조건을 유보함이 없이 모든 근로자에 대하여 세전임금기준으로 1개월분(100퍼센트)에 해당하는 금전을 성탄절상여금으로 지급하여 왔다. 그런데 1978년 이후부터는 사용자가 이를 지급하면서 별도로 회사 공고 란에 “성탄절 상여금(특별급여) - 근로자들은 위 상여금을 월급과는 별도로 사용자의 호의차원에서 지급받는 것이므로 장차에도 이에 관한 법적 청구권을 행사할 수는 없음”이라고 분명히 표시하였다. 이러한 방식으로 성탄절상여금의 세전임금 1개월 치 지급은 1992년도까지 이루어져 왔다. 그런데 1993년도에 사용자가 단체협약 상의 규정을 근거로 하여, 종래 지급하여 오던 상여금 액에서 30퍼센트를 삭감한 금전을 성탄절상여금을 지급하였다. 그러자 이에 반발하여 근로자들이 30퍼센트에 해당되는 차액을 추가로 지급할 것을 요구하였다.⁵⁰⁾

49) BAG NZA 1997, 1007.

50) BAG NZA 1997, 1007.

2) 판결의 내용과 근거

당시 법원은 이미 사용자가 1978년 이래로 성탄절 상여금 지급이 호의적인 것임을 공시하였고, 근로자도 이러한 공시에 별다른 이의를 제기한 바 없이 수년이 경과한 경우이므로, 1978년 이전까지 형성되어 온 노동관행은 소멸한 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 따라서 1978년 이후 비록 반복된 호의성 명시하의 상여금 지급으로 새로운 노동관행이 성립하였다고 본 것이다. 그 법도그마적 근거는 노동관행의 형성에서와 마찬가지로 당사자간의 급부내용에 있어 불이익변경은 묵시적 합의를 통해 인정된 것으로 보았다.⁵¹⁾ 이에 따라 동 사안에서 법원은 근로자의 노동관행에 기한 종래 급부지급 청구권 형성을 부인하였다. 결국 노동관행을 통해 형성된 청구권이 새로운 노동관행⁵²⁾을 통해 소멸되는 것을 인정하게 된 것이다.⁵³⁾ 이러한 판결의 입장은 크게 다음과 같은 두 가지 법 이론적 근거를 통해 뒷받침되었다.

(1) 거울이론(Spiegelbildtheorie)

“(청구권은) 발생한 방식으로 소멸한다(Wie gewonnen, so zernonnen)”.⁵⁴⁾ 이는 독일 연방노동법원이 밝힌 주된 법리로서, 이른바 ‘거울이론(Spiegelbildtheorie)’이라고 한다.⁵⁵⁾ 이 이론은 급부 청구권의 발생이 명시적 합의에 따른 것이든, 법률규정에 따른 것이든 혹은 묵시적 합의에 따른 것이든, 그 발생 방식에 따라 마찬가지로 소멸되어야 한다는 것이다.

원래 노동관행에 따른 종래 급부청구권의 발생에 있어서도 사용자는 자신의 급부지급을 계약상 의무로 부담할 의사가 없었음은 사실이다. 그러나 노동법은 사용자의 그러한 주관적 의사의 실체적 유무를 고려하지

51) BAG AP Nr.55 zu § 242 BGB Betriebliche Übung.

52) 이른바 ‘부정적 노동관행(Negative betriebliche Übung).

53) Bepler, RdA 2004, 239 (240ff.).

54) Maties, *Die gegenläufige betriebliche Übung*, 2003, S. 158 ff.; Speiger, NZA 1998, 510 (512).

55) 거울 속에 반사된 모습은 거울 앞에 서 있는 대상이 움직이는 대로 사라졌다가 생기고 하므로, 이를 본 때 거울이론이라 칭하고 있다.

않고 오히려 객관적으로 반복된 급부지급사실 그 자체에 주목하는 것이다. 사실상 그러한 사실로부터 사용자는 급부에 대한 법적 의무를 부담하게 되었으므로, 이러한 경우에는 마찬가지로의 방식으로 당해 급부 청구권이 소멸되거나, 불이익하게 변경될 수 있다고 하는 것이 형평에 부합하며,⁵⁶⁾ 논리상으로도 일관된다고 본 것이다.⁵⁷⁾

(2) 금반언의 원칙(venire contra factum proprium)

또한 법원은 노동관행의 내용에 대한 노동관행을 통한 불이익변경은 사용자의 신뢰보호라는 측면에서도 신의칙 상 긍정되어야 한다는 입장을 견지하고 있다.⁵⁸⁾ 앞의 사안에서 보듯이 사용자가 종래 노동관행으로 지급되어오던 급부에 대하여 불이익변경을 하였고 이에 대해 수년에 걸쳐 근로자 측이 아무런 이의를 제기한 바가 없었다면 적어도 사용자는 더 이상 종래 노동관행상 인정된 급부지급의무는 존재하지 않는다고 스스로 신뢰할 수 있게 된다. 왜냐하면 만약 근로자가 불이익변경 당시에 즉시 사용자에게 대하여 이의를 제기하였더라면 사용자는 근로자 측과 별도로 명시적 합의도출에 나서든지, 아니면 변경해지를 고려할 수 있었을 것이기 때문이다. 그런데 근로자 측에서 수차에 걸쳐서도 아무런 이의를 제기하지 않았으므로, 사용자로서는 사실상 근로자 측이 이러한 불이익변경에 대해 승낙한 것으로 파악할 수밖에 없다는 것이다. 따라서 만약 근로자가 그동안 아무런 이의를 제기하지 않다가 갑자기 종래의 급부지급을 요구하는 것은 금반언의 원칙에 반하는 것으로서 받아들여질 수 없다고 한다.

3. 비판적 평가

독일 연방노동법원의 입장인 거울이론에 따르면, 불이익 변경된 급부

56) BAG NZA 2003, 924; BAG NZA 2002, 54; BAG AP Nr.70 zu § 242 BGB Betriebliche Übung.

57) Maties, *Die gegenläufige betriebliche Übung*, 2003, S. 158 ff.

58) BAG NZA 1997, 1007.

부분에 대하여도 사실상 묵시적 합의를 통한 합의로서 새로운 부정적 노동관행이 성립한 것으로 본다. 그런데 불이익 변경에 관한 당사자 간의 묵시적 합의가 존재한다고 볼 수 있는가는 다음과 같은 이유에서 의문이 아닐 수 없다.

1) '청약'의 의사표시 흠결

우선 사용자의 불이익 변경된 급부지급(혹은 급부의 비지급)의 반복에 대하여 청약의 의사표시성을 인정할 수 없다. 왜냐하면 사용자는 불이익 변경에 따른 급부지급사실은 단지 근로자 측에 일방적으로 그 변경을 알리는 것에 불과하고, 근로자로 하여금 이에 동의하겠는가 여부를 묻는 것이 아니기 때문이다.⁵⁹⁾ 종래의 계약내용과 다르게 행위 하겠다는 일방적인 단순 의사표명을, 종래 청구권으로서 계약의 내용을 형성한 급부를 폐지토록 하는 데 대한 청약으로 파악할 수는 없다.⁶⁰⁾ 이러한 점에서 청약의 의사표시가 존재하지 않는다고 보아야 한다.

2) '승낙'의 의사표시 흠결

법원의 입장은 또한 근로자 측의 이의제기 없음에 대하여 승낙의 의사표시성을 긍정하지만, 이 역시 다음과 같은 점을 고려할 때 설득력이 없다.

(1) 침묵과 이의제기

원칙상 사법적 계약관계에서 당사자의 침묵은 곧 거절을 의미한다.⁶¹⁾ 침묵이 승낙으로 평가되는 경우는 원칙상 당사자가 적극적으로 자신의 의사를 표명해야 하는 상황을 전제로 하여서만 그렇다. 근로자는 근로계약 내용의 불이익한 변경된 급부를 수령하면서도 별도의 이의를 제기해야 하는 것은 아니다. 노동관행상의 급부와 관련하여 사용자는 일정한

59) Speiger, NZA 1998, 510 (512).

60) Thüsing, NZA 2005, 718 (720); Speiger, NZA 1998, 510 (512).

61) Thüsing, NZA 2005, 718 (720f.).

급부의 계속제공여부 그 자체는 물론이고, 이를 불이익하게 변경하여 지급할 것인가 여부도 스스로 자유롭게 결정하고 실행할 수 있다.⁶²⁾ 그런데 만약 법원의 입장과 같이 근로자의 이익제기 없음을 불이익 변경에 대한 승낙으로 본다면, 근로자는 사용자의 급부행위에 대해 이익을 제기하는 등 반드시 대응하여야 하는 상황을 감수해야 한다.⁶³⁾ 왜냐하면 근로자 측 입장에서는 사용자의 그러한 결정에 대해 반드시 대응조치를 하지 않으면 당해 청구권을 상실하는 결과가 되고 말기 때문이다.⁶⁴⁾ 정작 독일연방노동법원은 어떠한 근거에서 사용자는 자유로운 결정을 통해 스스로 급부를 지급할 수 있는 반면 근로자는 이에 대해 반드시 대응해야 하는 가를 분명히 해명하지 못하고 있다.⁶⁵⁾ 노동관행 상의 불이익 변경과 관련하여 통상 근로자는 별도의 이익을 제기하는 등 대응을 하지 않고, 단지 침묵하였다는 사실만으로 승낙의 의사표시로서의 적격성을 인정할 수 없는 이유가 바로 여기에 있다.

(2) 근로자의 수동적 지위

사용자의 불이익 변경된 급부지급행위는 ‘선제적’이며, ‘적극적’인 지위에서 행하여진다. 이에 비하여 근로자는 단지 당해 급부를 수령하는 ‘수동적’ 지위에 있다. 이러한 수동적 지위에서 있는 근로자로 하여금 사용자에게 대하여 그때마다 적극적인 의사 개진을 하도록 기대하는 것은 현실적으로 무리이다.⁶⁶⁾ 왜냐하면 근로자는 사용자에게 대하여 계약적 약자로서의 지위에 있기 때문이다. 이러한 점은, 종래와 동일한 급부를 여전히 지급하면서 단지 당해 급부의 호의성을 명시적으로 유보하기만 한 경우⁶⁷⁾ 등에서 더욱 분명히 나타난다. 예컨대 판례에서 문제된 사례에서

62) Thüsing, NZA 2005, 718 (720f.).

63) Spieger, NZA 1998, 510 (512).

64) Spieger, NZA 1998, 510 (512).

65) Spieger, NZA 1998, 510 (512).

66) Spieger, NZA 1998, 510 (512, 513).

67) 종래 노동관행상의 급부청구권이 형성된 이후에, 당해 급부에 대해 사용자가 호의적 급부성을 새롭게 유보하는 것은 당해 급부의 성질변화를 초래하는 불이익변경이 된다.

보듯이, 사용자가 종래 수년에 걸쳐 1개월 임금에 해당하는 성탄절상여금을 지급하여 오다가, 이후 호의적 급부성을 분명히 하면서 이후 5년에 걸쳐 동일금액의 성탄절상여금을 지급한 경우에, 근로자 측이 이익을 제기하도록 기대하는 것은 근로자의 수동적 지위를 고려할 때 무리가 아닐 수 없다.⁶⁸⁾ 왜냐하면 근로자로서는 종래와 동일한 상여금을 현실적으로 받고 있었기 때문이다.

3) 노동법상의 고유한 법원으로서 노동관행

마지막으로 노동관행이 노동법상에서 고유하게 인정되는 법원이라는 점을 고려할 필요가 있다. 노동관행은 근로자 측에 유리한 급부가 반복되는 경우에 비로소 사용자와 근로자 간의 분명한 의사표시 없이 일정한 법적 청구권을 근거 지운다. 이러한 점에서 다른 일반적 채권계약관계와 구별되는 특유성이 있다. 종래 사용자의 호의적 급부지급이 사실상 계약의 내용으로 변경되어 일정한 청구권을 정당하게 근거지우는 것이라면 그 소멸도 마찬가지로 방식으로 이루어질 수 있다는 연방노동법원의 논리는 이러한 측면을 간과하고 있다고 보아야 한다. 왜냐하면 근로자에 유리한 급부청구권의 생성은 노동관행이라는 노동법상 고유한 법원이 기능하는 영역이지만, 그 소멸이나 불이익 변경을 위하여 노동관행이라는 법원이 다시금 고려될 여지는 없기 때문이다. 다시 말하면 노동법상 법원으로서 노동관행은 근로자 측에 유리한 급부의 반복적 지급의 경우에 법원이 재판의 규범으로서 이를 고려할 수 있는 것이지, 근로자 측에 불리하게 실행되고 있는 사실에 대해서까지 의사표시로서의 적격성을 부여할 수 있는 것은 아니다.

4. 소결

기왕에 성립된 노동관행 상의 급부청구권의 내용을 불이익하게 변경하는 경우에, 단순히 변경된 급부를 반복하여 지급하였고, 근로자가 이를

68) Preis, *Arbeitsrecht*, 2. Aufl., 2003, S.168ff.

수령하면서 별도의 이의를 제기하지 않은 사실만으로 이른바 종래 노동관행상의 급부청구권 내용을 변경하는 새로운 노동관행이 성립한다고 볼 수는 없다. 왜냐하면 묵시적 계약을 위한 청약의 의사표시와 승낙의 의사표시가 각각 흠결되어 있기 때문이다. 따라서 이러한 의사표시의 흠결에도 불구하고, 묵시적 합의에 따른 급부내용의 불이익 변경을 인정한 독일 법원의 입장은 설득력이 없다.

V. 요약 및 결론

1. 노동법상의 특유한 법원으로서 노동관행에 대해 그 법적 본질을 설명하는 것은 매우 어려운 일이다. 무엇보다 반복된 객관적 사실로부터 일정한 법적 청구권이 형성된다는 것 자체가 처음부터 사법이론상 매우 생소한 일이기 때문이다.

2. 노동관행으로부터 일정한 청구권을 성립하게 하는 근거에 관하여 종래 우리 학설은 노동관습법 또는 사실인 관습 차원에서 파악하고 있다. 그러나 일정한 급부지급이 관습에 이른 정도의 경우에만 청구권으로서 인정된다는 것은 지나치게 그 인정범위가 좁다. 적어도 관습에 이를 정도의 반복적 급부에 대하여만 청구권의 발생을 인정하게 되기 때문이다. 하지만 노동관행상의 반복적 급부지급이 청구권성을 지니는 것은 관습에 이를 정도임을 요한다고 보기 어렵다. 이러한 점에서 관습으로서의 실질을 전제로 하여 급부청구권의 발생을 인정하게 되는 종래 우리의 입장은 지지하기 어렵다.

3. 이에 대해 종래 독일에서는 주로 노동관행에 대해 계약체결에 따른 결과라는 견해(계약설)와 신뢰보호차원에서 인정된다는 견해(신뢰책임설)가 대립하여 왔다. 그러나 신뢰책임설은 노동관행에 따른 청구권과 관련하여, 이에 부수되는 근로자의 의무부담을 설명할 수 없다는 흠이 있다. 따라서 비록 반복된 객관적 사실에 대하여 일정한 주관적 의사표시성을

부여하는 이론적 어려움이 있으나, 노동관행상의 급부에 부수한 근로자의 의무부담까지도 효과적으로 설명할 수 있다는 점에서 당사자 간의 묵시적 계약으로 보는 것이 타당하다고 본다.

4. 노동관행에 기한 급부청구권을 사용자가 배제하거나 그 내용을 불이익하게 변경하고자 하는 경우에는 원칙적으로 근로자 측과 합의를 도출하여야 한다. 이를 위해 우리의 경우는 취업규칙의 불이익 변경에 준하여 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의 등 근로자 측의 집단적 동의를 얻는 것이 필요함은 앞서 설명한 바 있다. 그러나 독일연방노동법원의 입장과 같이 아무런 합의를 도출함이 없이 사용자의 일방적인 종래 급부의 불지급 사실 등으로부터 종래의 청구권이 배제될 수는 없다. 왜냐하면 노동관행에 기한 청구권의 성립 시와는 달리 그 폐지 시에는 묵시적 합의를 도출하기 위한 당사자 간의 의사표시로서 청약과 승낙이 존재한다고 보기 어렵기 때문이다.

주제어 : 노동관행, 계약설, 신뢰책임설, 금반언의 원칙, 사실인 관습, 청약, 승낙, 부정적 노동관행, 거울이론, 변경해지, 묵시적 합의

Key words: betriebliche Übung, Vertragstheorie, Vertrauenshaftung, venire contra factum proprium, Angebot, Annahme, negative Betriebsübung, Spiegelbildtheorie, Änderungskündigung, stillschweigende Vereinbarung.

<Zusammenfassung>

Dogmatische Grundlage zur Begründung oder zur
Beseitigung des Leistungsanspruchs aus der
betrieblichen Übung

Kwon, Hyuk*

Zwar schon seit 1920er hat das Institut der betrieblichen Übung zu einem festen Bestandteil des deutschen Arbeitsrechts entwickelt. Aber es ist nicht zu leugnen, dass die dogmatische Grundlage der betrieblichen Übung bisher noch unklar bleibt. Die Kernfrage liegt darin, aus welchem Grund die regelmäßige Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen des Arbeitgebers, die der Arbeitnehmer eine Leistung oder Vergünstigung auf Dauer einräumen, den Arbeitgeber auch für die Zukunft rechtlich bindet. Als Lösungsmodell halten sich eine Vertragstheorie und eine Vertrauensstheorie die Waage. Meiner Meinung nach ist die Vertrauenshaftung zur Begründung des auf betriebliche Übung gestützten Anspruchs nicht zuzustimmen. Denn die Frage, in welcher Weise die Verpflichtung des Arbeitnehmers aus der betrieblichen Übung zu erklären ist, ist aus dem Gesicht der Vertrauenshaftung nicht zu beantworten. Somit ist die rechtsdogmatische Grundlage in der stillschweigenden Vertragsschluss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finden. Noch geht es um die Auflösung des aus einer betrieblichen Übung anerkannten Anspruchs. Anders als bisherige Auffassung werde nach neuer Rechtsprechung in Deutschland die bisher bestehende betriebliche Übung geändert, wenn der Arbeitnehmer der neuen Handhabung über

* Privat Dozent an der Korea Universität

einen Zeitraum von drei Jahren nicht widerspricht. Das bedeutet, dass die betriebliche Übung verneint werden soll, wenn der Arbeitgeber klar und unmissverständlich erklärt, die Zahlung einer auf betrieblicher Übung beruhenden Zuwendung nur noch unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit erbringen zu wollen. Wesentliche Stütze der Argumentation des BAG bei Entdeckung der negativen betrieblichen Übung war der Vergleich zum Entstehen der betrieblichen Übung. Die Beseitigung sei an gleichartige Anforderungen zu knüpfen. Das Verhalten des Arbeitgebers besteht nämlich aus einem aktiven Tun, der veränderten Leistungserbringung. Demgegenüber handelt der Arbeitnehmer passiv, er nimmt die Leistungen in Kenntnis des zwischenzeitlich erklärten Vorbehaltes widerspruchslos entgegen. Weitere Unterschiede ergeben sich auch bei der Verhaltensmotivation. Der Arbeitgeber erbringt die Leistungen zunächst aufgrund einer vom Arbeitnehmer nicht beeinflussbaren, freien Entscheidung. Damit ist es nicht zuzustimmen, die Widerspruchlosigkeit der Arbeitnehmer als eine Annahmeerklärung zu bewerten. Damit ist es abzulehnen, dass es eigentlich eine Vereinbarung über die ungünstige Veränderung der betrieblichen Übung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt.

Konsequenterweise für die Reduzierung von Gratifikationsleistungen sind nur die Änderungskündigung und die Änderungsvereinbarung zu berücksichtigen. Also ist die Begründung der negativen Betriebsübung begrifflich zu verneinen.